

1502455-67.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502455-67.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502455-67.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341452/2021 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21969361 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 797/21/135 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2341452 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

WESLLEY DA CRUZ CORREA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

WESLEY DA CRUZ CORREA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Jurubeba, nº 100, bairro Botujuru, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, guardava, transportava e expunha a venda drogas consistentes em 87g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 58 invólucros plásticos; 32,2g de cocaína, acondicionadas em 45 invólucros plásticos; e 15,1g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 84 eppendorfs, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14, e laudo de constatação de fls. 22/24.

Segundo o apurado, na data e local acima indicados, o acusado guardava e expunha a venda cento e oitenta e sete embalagens individuais de drogas.

Consta dos autos que policiais civis realizavam diligências em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando avistaram o acusado entregando objetos a populares que passavam por ali que, em troca, entregavam dinheiro a ele.

Diante da atitude suspeita, os policiais se aproximaram e efetuaram a abordagem. Em revista pessoal, localizaram uma sacola na posse do acusado, dentro da qual havia 45 invólucros com cocaína, 58 invólucros com maconha e 84 eppendorfs contendo crack, além da quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Indagado, o acusado confessou a prática do crime.

A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro, bem como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial às págs. 07/47. Notificado a pág.109, o réu ofertou defesa preliminar (pág.116). Recebida a denúncia às págs.117/118, o réu foi citado (pág.134). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, a acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia, reconhecimento de tráfico privilegiado com redução mínima e a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. E, subsidiariamente, regime mais benéfico e aplicação de benefícios em favor do agente.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito vem demonstrada no auto de exibição e apreensão juntado a pág.20 (dinheiro e droga); nas imagens de págs.25/27, nos laudos de constatação (págs. 28/30) e químico-toxicológico (págs.102/104), bem como no comprovante de depósito a pág.54.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial a (pág.11), em Juízo o acusado confessou a prática do crime nos termos da denúncia, aduzindo que praticava o tráfico de droga pela primeira vez, na data do fato.

Para justificar a conduta, aduziu que precisava de dinheiro para pagar dívida.

Havia sido ameaçado.

O réu confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido: "Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

A confissão, ademais, veio corroborada sob o crivo do contraditório nos depoimentos dos policiais civis Djair Oliveira Souza e Richard Fernandes, que em relato coeso e

harmônico com o anterior relataram os passos da diligência encetada na data dos fatos e espancaram qualquer dúvida quanto à autoria:

O local é conhecido ponto de tráfico de droga. Para lá se dirigiram e realizaram breve campanha com viatura descaracterizada. Avistaram o acusado em atitude típica da mercancia ilícita. Recebia algo do solicitante e entregava objeto que retirava da sacola que estava em seu poder.

Diante da suspeita conduta, aproximaram-se e efetuaram a abordagem. Em revista pessoal, localizaram na sacola que o agente portava 45 invólucros com cocaína, 58 invólucros com maconha e 84 eppendorfs contendo crack, além da quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Indagado, o acusado, que não aparentava estar sob o efeito de droga, confessou a prática do crime. Não forneceu justificativa.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

[Fato é que inexistente o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015). Quanto à ausência de qualificação de testemunhas civis ou usuários de droga, os policiais relataram a dificuldade da diligência, que leva a equipe a priorizar a abordagem do traficante.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (58 invólucros plásticos de maconha, 45 invólucros plásticos de cocaína e 84 eppendorfs contendo crack), a forma como acondicionada (individualmente), a apreensão de dinheiro trocado e as circunstâncias da prisão (atitude suspeita em local conhecido pela prática da mercancia ilícita), tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do citado Diploma.

Consigne-se que, embora o réu não tenha sido preso enquanto efetuava a venda da droga apreendida, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia. Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se inserem aquelas imputadas ao acusado na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu. Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

WESLLEY declarou que não estava drogado durante a ação criminosa. Tinha ingerido álcool, mas em relação a tal substância afastou dependência química.

Para justificar a conduta, o acusado afirmou que precisava de dinheiro para pagar dívida. Não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não autoriza a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida.

De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade do acusado, muito menos que agira visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa (CPP, art.156).

O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)". (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las.

Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)". (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Também não há prova de coação moral irresistível (o réu alegou ter sido ameaçado para pagar dívida).

Segundo a doutrina, a coação existe quando há o emprego de força física ou de grave ameaça para sujeitar o sujeito à prática do ilícito.

Na coação moral – tese defensiva – existe a ameaça, de modo que a vontade do coacto não é livre, embora possa decidir pelo que considere para si um mal menor, não lhe sendo exigível comportamento diverso.

Em qualquer hipótese, porém, exige o art. 22 do Código Penal, para excluir a

culpabilidade, que a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, ou seja, uma força a que o coacto não pode subtrair-se ou enfrentar.

Portanto, é indispensável que no caso concreto se examinem as condições de resistibilidade do coacto, levando-se em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como suas condições pessoais (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, Atlas, 7ª Ed., p. 105/106).

No caso em tela não ficaram demonstrados os requisitos legais de tal dirimente, que não encontra respaldo em qualquer elemento de prova carreado aos autos, ônus que incumbia ao réu (CPP, art.156).

Tampouco demonstrou o acusado que não poderia se valer dos caminhos legais para a solução da questão.

A propósito:

“A alegação de coação irresistível exige demonstração de prova indubitosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, resumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal” (RJTACRIM 55/78).

“Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação dos réus, especialmente quando a descrição dos fatos por eles fornecida encontra-se rebatida por prova em contrário” (TACRSP, RT 813/596).

“A alegação de coação irresistível exige demonstração de prova indubitosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, presumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal” (RJTACRIM 55/78).

Portanto, o acusado realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado, primário e sem antecedentes criminais na data do fato. Não se sobressai, no fato em tela, maior grau de censurabilidade da conduta do agente, inerente ao tipo penal em espécie. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Não incidem agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento de pena.

Incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O réu preenche todos os predicados legalmente previstos. É primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova de que, na época dos fatos, se dedicava à atividade criminosa ou integra organização criminosa.

Todavia, há óbice à aplicação do índice redutor máximo.

Com efeito, não é possível olvidar a razoável quantidade de droga - de natureza diversa - apreendida - 187 porções (58 invólucros plásticos de maconha, 45 invólucros plásticos de cocaína e 84 eppendorfs contendo crack).

O benefício de redução de pena previsto no mencionado §4º não foi instituído pelo legislador para atuar como redutor máximo automático das sanções correspondentes ao tráfico de droga no grau máximo. Teve o escopo de disponibilizar ao Juiz um espectro mais amplo de opções no momento de individualizar as reprimendas correspondentes a esse delito.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que na forma de pó ou pedra tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a

saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína. O crime é de perigo abstrato.

Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a “natureza” (ou “qualidade”) e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.

Assim, pelas razões alhures, reduzo a pena em 5/12, o que perfaz 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 291 dias-multa. O índice é proporcional à conduta perpetrada pelo acusado.

A jurisprudência majoritária acolhe o entendimento de que tais circunstâncias devem ser apuradas nesta etapa da dosimetria da pena, método compatível com a melhor hermenêutica e mais próximo da correta interpretação e aplicação do Direito como ciência (Apelação Criminal nº 0003571-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 11/05/2010; Apelação Criminal nº 0074313-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/08/2011; Apelação Criminal nº 0011319-96.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/10/2012).

Ainda nessa linha:

AgRg no HC 209930/ES, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Julgado em 18/10/2012; HC 244726/ES, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 18/10/2012.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o aberto, pois reconhecida a incidência do furto privilegiado (observe-se que, embora conste a prisão do acusado por tráfico de droga após os fatos, a denúncia ainda não foi recebida nos autos que tratam deste suposto novo delito, cf. certidão criminal juntada aos autos.

Considera-se, outrossim, a situação do acusado na época do fato).

Não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena não altera a tipificação contida no caput do referido preceito legal (ou seja, em que pese a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada tráfico de drogas, ainda hediondo).

Esse entendimento chegou a ser reforçado pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça:

“A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.” (Súmula 512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).

Ocorre que, no julgamento do HC nº 118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Para o Supremo Tribunal Federal, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência.

Essa decisão foi acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a

Súmula 512, em 2016.

Ainda assim, tais decisões encontravam-se desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam adstritos ao entendimento ali professado.

Ante a inexistência de resolução do Senado acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram seu posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes de natureza hedionda.

Esse foi no entendimento perfilhado por este Juízo por anos, mantendo-se a natureza de crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ocorre que a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”) trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...)”

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º (“tráfico privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o “tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que tais delitos “apresentam contornos menos graves e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.

Adotar uma premissa válida para a Lei de Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas medidas”.

A persecução penal, fundamentalmente, está separada em três fases bem distintas, a saber:

A investigação, o processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo, dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés, continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de conhecimento. O direito é único.

No entanto, o direito, como ciência que é, está sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação social, possibilitando, sempre, sua interpretação e modificação de entendimento, no todo, ou em parte.

Por tais razões, este Juízo alterou, nessa parte, posicionamento anterior, depois de muita reflexão e ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente, quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao regime inicial para expiação da pena corporal.

Diante das alterações legislativas recentes, deve ser realizada interpretação sistemática, passando-se a adotar o tráfico privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto.

Fundamenta-se o regime na exegese do artigo 59, caput, e seu inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pena base foi fixada no mínimo legal. O réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedicava à atividades criminosas na data do fato. Confessou a prática do crime. Sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2º,

alínea "c", do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Cumpre-se, outrossim, a recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP.

De outra parte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A concessão de tais benesses descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Na espécie, o réu portava quantidade razoável de droga. Embora seja possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito não constitui medida recomendável pois não teria o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) torna a conduta incompatível com aquelas benesses, mormente em relação à cocaína, que tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do inculpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína.

O crime é de perigo abstrato.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado WESLEY DA CRUZ CORREA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado.

O réu respondeu ao processo preso (págs.58/63). Diante da pena e regime aplicados, o réu poderá recorrer em liberdade, não mais presentes os requisitos da prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Decreto o perdimento do dinheiro, oriundo do tráfico de droga.

De imediato, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição da substância entorpecente apreendida nos autos.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA